Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Autos nº 0830510-52.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor:Euda Maria de Lima Lopes
Réu:Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA

Vistos, etc.

1 – RELATÓRIO

Euda Maria de Lima Lopes ajuizou(aram) a presente demanda em face de **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, aduzindo, em resumo, que:

(**i**) a requerente Euda Maria de Lima Lopes é acometida de neoplasia da mama (CID 10 C 50) a doença foi diagnostica em 2013, foi submetida à mastectomia à direita, seguido 06 meses de quimioterapia adjuvante e radioterapia;

(**ii**) em agosto 2020 surgiram nódulos cervicais e supraclaviculares, sendo submetida a linfadenectomia cervical esquerda, devido a análise anatomopatológica confirmando recidivada doença, com característica de apresentar positividade para receptores hormonais;

(**iii**) para tratamento foi proposto uso de medicamento (Ibrance e hormonioterapia – fulvestranto), mas houve negativa do plano de saúde;

(**iv**) a negativa do plano de saúde é indevida porque há previsão no art. 21, da Resolução 428/2017, da ANS que impõe o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

(**v**) o medicamento já foi nacionalizado e tem registro na anvisa,

(**vi**) requereu *tutela de urgência* para determinar que a requerida forneça o medicamento indicado.

(**v**) requereu, ao final, a procedência da demanda para:

(a) condenar a requerida a custear e fornecer o medicamento indicado na inicial;

(b) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Com a inicial vieram os documentos de f. 27/51.

Despacho inicial às f. 53/58.

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu *contestação* às f. 82/110, oportunidade em que sustentou preliminares, além de alegar, no mérito, em resumo, que:

(**i**) impossibilidade de cobertura porque o medicamento não está incluído no rol de eventos cobertos pela ANS, havendo expressa exclusão no contrato;

(**ii**) o procedimento terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer é de cobertura obrigatória pelo rol de procedimentos da ANS, contudo, deverá ser observado nas diretrizes de utilização dispostas no item 64, do Anexo II, da RN n. 428/2017 quais os medicamentos cobertos e indicados a cada patologia, sendo que existem outros medicamentos cobertos pelo plano;

(**iii**) o medicamento não está contemplado nas Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar e não está previsto no rol de cobertura mínima do Rol da ANS que teria expressa previsão contratual;

(**iv**) as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas, simplesmente, a autorizar os eventos e procedimentos solicitados pelos médicos assistentes, eis que possuem o direito e deve de promoverem a devida análise do quanto está sendo solicitado, até mesmo para segurança e benefício do próprio beneficiário;

(**v**) não é razoável que a requerida seja compelida à concessão do medicamento,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

nos moldes requeridos, tendo em vista ausência de cobertura e que a sua concessão ensejará obrigação excessivamente onerosa à Unimed Campo Grande;

(**vi**) taxatividade do rol de eventos e procedimentos previstos na ANS;

(**vii**) inocorrência de danos morais;

(**viii**) requereu a total improcedência da demanda; juntou documentos.

Decurso do prazo sem apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 343).

Oportunizada especificação de provas (fls. 347).

Manifestação pela requerida (fls. 350/352).

Decisão que indeferiu as provas (art. 370, paragrafo único, CPC) e oportunizou a apresentação de memoriais (fls. 354).

Alegações finais pelo réu (fls. 357/365), havendo omissão da autora (fls. 366).

É o relatório.

Fundamento e **DECIDO.**

2 – MOTIVAÇÃO

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Nos termos do **art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil**, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito *"quando não houver necessidade de produção de outras provas"*.

Na espécie, é desnecessária a dilação adicional probatória em relação às constantes nos autos, de modo que não há razão para prolongação do processo no tempo, o que acabaria por obstar a prestação jurisdicional rápida, efetiva e adequada, afrontando,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

por consequência, o princípio da economia processual.

Desse modo, em estrita observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no **art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal**, que prevê que *"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"*, também positivado no **art. 4º, do Código de Processo Civil**, passo ao julgamento antecipado do mérito do processo.

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Sustenta a requerida que a autora indicou erroneamente o valor de R$ 516.375,89, sendo que o valor adequado seria R$ 231.303,88, correspondente a um ano de tratamento.

A impugnação deve ser acolhida, porque, de fato, o valor indicado pelo autor está em desacordo com as previsões contidas no art. 292, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o art. 292, §2º, do CPC, determina que o valor da causa corresponderá o montante das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Assim, considerando que há previsão de que o tratamento será de 28 meses, deverá ser limitado há 12 meses, correspondendo, portanto a R$ 269.166,24 (12 x R$ 22.430,52).

Necessário ainda a cumulação do valor pedido a título de danos morais R$

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

10.000,00, conforme art. 292, VI, do Código de Processo Civil.

Assim, acolho a impugnação ao valor da causa e fixo em R$ 279.166,24.

DO MÉRITO

Na espécie, a relação havida entre as partes rege-se pelas regras da lei 8.078/90, sendo a parte autora considerada consumidora, *ex vi* do **art. 2°, do Código de Defesa do Consumidor**, que conceitua *"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"*, tratando-se de hipótese que há nítida condição de vulnerabilidade.

Ademais, a parte requerida é considerada *fornecedora*, que, segundo o **art. 3°, do CDC**, *"fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços"*, sendo que *"produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial"* (**CDC 3º, § 1º**) e *"serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista"* (**CDC 3º, § 2º**).

Outrossim, ao caso aplica-se a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Com efeito, ao contratar um plano de saúde, o consumidor tem como objetivo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

a segurança de que, no futuro, se necessitar de algum tratamento médico, será garantida a cobertura das respectivas despesas. Em contrapartida, despende mensalmente determinada quantia em favor da operadora do plano.

Logo, é imposição legal a interpretação do contrato de maneira mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas, que coloquem em desequilíbrio a relação contratual.

Assim, a questão está amparada pela tutela consumerista e suas regras especiais.

Feitos estes esclarecimentos prévios, verifica-se que a vigência do contrato de plano de saúde e a negativa do custeio do tratamento são fatos incontroversos.

Sustenta a demandada, em suas defesas, que o tratamento requerido não é coberto, em razão da exclusão contratual, bem como ponderando que o mesmo não se encontra em rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde.

Os documentos que instruem a inicial dos autos em análise são suficientes para amparar a procedência dos pedidos.

Ressalte-se, desde logo, que o beneficiário está sob os cuidados de profissional da medicina e se este profissional, analisando a situação individualizada, receitou-lhe determinado tratamento médico para garantir a vida e saúde do paciente.

Dessa forma, é irrelevante o fato de haver soluções alternativas, pois tendo em os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o direito à vida digna deve prevalecer sobre eventual ausência contratual.

O fato de inexistir, ao tempo da solicitação, previsão de cobertura para o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

tratamento em questão no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ao qual supostamente está limitado o contrato) também não possui o condão de tornar legítima a recusa da ré, tampouco serve de fundamento para tanto, porquanto referido catálogo busca apenas determinar os procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando exclusão obrigatória dos demais, como busca fazer crer.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, veiculando os procedimentos mínimos a serem assegurados aos pacientes, não impedindo coberturas mais amplas, sobretudo ao se interpretar o contrato dentro do contexto do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º, inciso III, impõe o dever de informação aos fornecedores nas hipóteses de exclusões de cobertura contratual.

Em especial considerando que tal entendimento foi positivado expressamente na Lei 9656/98, que prevê a possibilidade de cobertura de procedimento que não conste do rol mínimo.

> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em análise o laudo médico indica a necessidade do medicamento indicado na inicial:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Por isso solicito a associação de Ibrance (palbociclibe) à hormonioterapia (fulvestranto), conforme prescrição anexa. A indicação desse medicamento está de acordo com em bula, para uso associado à hormonioterapia em pacientes com câncer de mama hormônio-sensível. Baseado no estudo PALOMA-3, (N Engl J Med 2018; 379:1926-1936), que evidenciou aumento de 6,9 meses na sobrevida global (34,9 meses comparado com 28 meses com apenas hormonioterapia).

Esse medicamento, Ibrance (palbociclibe), é aprovado pela ANVISA, para esta indicação. Não é medicamento manipulável, não há medicamento genérico ou similar, não há outra opção terapêutica disponível para esta paciente e necessita iniciar o mais breve possível. A não utilização desse medicamento pode reduzir o tempo de vida da paciente.

No caso em tela, o contrato prevê o cobertura para a moléstia da autora, o que é incontroverso nos autos, devendo se estender a todos os tipos de tratamentos relativos à doença. Isso porque quando se estabelece cobertura para o tratamento está implícito que os medicamentos necessários para tanto estão acobertados pelo plano.

Destaca-se que a prescrição é específica ao informar que não há outra opção terapêutica disponível para o caso da autora, o que indica a impossibilidade de acolher o argumento do réu de que deveria fornecer medicamento diverso.

Nesse sentido existem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça:

> RECURSO DE APELAÇÃO – APELANTE UNIMED DE DOURADOS – AUTORA COM CÂNCER DE MAMA – 61 ANOS DE IDADE – NECESSITA DO FÁRMACO IBRANCE – NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RAZÕES AFASTADAS – FÁRMACO REGISTRADO PELA ANVISA DESDE 2018 – RECUSA DE FORNECIMENTO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
>
> (**TJMS**. Apelação Cível n. 0809416-16.2018.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 18/12/2019, p: 07/01/2020)
>
> RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUTORA COM CÂNCER DE MAMA – NECESSITA DO FÁRMACO IBRANCE – SENTENÇA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

PROCEDENTE - APELANTE UNIMED DE CAMPINAS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(**TJMS**. Apelação Cível n. 0833930-65.2020.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 19/10/2021, p: 25/10/2021)

Destaca-se que, a ANVISA pelo PARECER PÚBLICO DE AVALIAÇÃO DO MEDICAMENTO – APROVAÇÃO de 01/03/2018, indicou que o medicamento possuía as seguintes indicações: "*Em combinação com terapia endócrina, é indicado para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático receptor hormonal (RH)-positivo, receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2)-negativo: - com letrozol como terapia endócrina inicial em mulheres pós-menopausa; - com fulvestranto em mulheres que receberam terapia prévia*".[1]

Ademais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro sanitário MS nº 1.0216.0257 para o medicamento IbranceTM no Diário Oficial de União n° 25 em 05/02/2018, através da Resolução-RE n ° 303 de 01/02/2018.

Portanto, mostra-se abusiva a recusa no custeio do tratamento apenas pela alegação de que o medicamento não se enquadra no rol de medicamentos de cobertura obrigatória. Afinal, os usuários são compelidos a aderir aos planos de saúde para ter assistência médica se e quando precisarem dela, e na medida necessária. Em contrapartida desta transferência de riscos futuros, os usuários pagam, de forma antecipada, regular e constante, determinada quantia de dinheiro.

Ainda, não há prova de que parte autora foi cientificada acerca da exclusão da cobertura para a medicação especifica indicada pelo profissional médico para tratamento,

[1] Consulta disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351324949201619/?nomeProduto=ibrance

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

o que afronta a legislação consumerista, que garante a informação prévia, clara e objetiva dos produtos e serviços e suas condições, porquanto *"as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão"* (CDC 54, § 4º).

Aliás, essa prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, era ônus que incumbia ao requerido, tendo em vista a inviabilidade de se impor ao consumidor a obrigação de comprovar um fato negativo.

Logo, considerando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente, entende- se, no caso presente, que os tratamentos demandados pelo autor devem ser custeados pela operadora do plano de saúde, porque indicados pelo médico responsável pelo paciente, não sendo dado ao plano de saúde, desse modo, interferir na técnica indicada.

Em situações semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento:

> E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO – MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER – RECUSA INDEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. 1. Discute-se no presente recurso a responsabilidade das ré-recorrente em custear o tratamento pleiteado pela autora-recorrida. 2. Quando o plano de saúde incluir atendimento ambulatorial deverá dar cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (artigo 12 da Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998). 3. O contrato de seguro-saúde não necessita cobrir todas as despesas relativas à saúde, desde que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

seu objeto e, consequentemente, os riscos excluídos, resultem de cláusulas não abusivas e que tenham redação clara. No caso, a paciente comprova que necessitava do tratamento médico pleiteado, portanto foi abusiva a recusa da requerida-recorrente em custear o tratamento médico de fundamental importância para a saúde e qualidade de vida da beneficiária, por impor à consumidora onerosidade excessiva e frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico celebrado. 4. No âmbito recursal, os honorários de sucumbência deverão ser majorados se a parte que deu causa à demanda recursal for sucumbente (art. 85, §§ 2.°, 3.° e 11, do Código de Processo Civil/15). 5. Apelação conhecida e não provida. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0804258-14.2017.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 27/07/2018, p: 31/07/2018 – sem grifos no original)

Ainda, existem decisões de outros Tribunais que reconheceram a abusividade da recusa na cobertura do medicamento indicado na inicial:

PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Autora diagnosticada com lipossarcoma abdominal. Prescrição do medicamento "Imbrance". Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da ré. Medicamento que corresponde ao tratamento da doença. Abusividade na recusa do fornecimento da medicação. Aplicação da tese 95 deste e. TJSP. DANOS MORAIS. Fatos narrados que extrapolam o mero aborrecimento. Danos morais configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1010025-80.2022.8.26.0100; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 21/09/2022)

APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO, À LUZ DE RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO IBRANCE (PALBOCICLIBE). PROCEDÊNCIA. Recusa. Ilegalidade. Alegação de não cobertura de métodos e tratamentos, por ausência de obrigatoriedade e por não constarem do rol da ANS. Impossibilidade. Recomendação prescrita, indispensável ao tratamento e cuidados especiais necessários para o quadro clínico. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Recente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

entendimento da Quarta Turma do STJ que não possui caráter vinculante e que deve ser ponderado com outras decisões proferidas por aquela mesma Corte Superior. Súmula nº 102 do E. TJSP. Medicamento que, posteriormente, acabou incorporado pelo rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1104121-29.2018.8.26.0100; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2022; Data de Registro: 23/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IBRANCE. NEOPLASIA DE MAMA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBERTURA DEVIDA. 1. A INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO NÃO IMPLICA INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ARTS. 421 E 422 DO CC). O ART. 423 DO CC DETERMINA QUE, NO CONTRATO DE ADESÃO, DEVE-SE ADOTAR A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. 2. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO CONTRATO PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. 3. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA COMPROVOU A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO USO DA MEDICAÇÃO CUJA COBERTURA FOI NEGADA PELA RÉ. 4. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO, PREVENDO APENAS A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA A SER ASSEGURADA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50108399220198210027, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-04-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER O MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O MESMO NÃO INTEGRA O ROL DA ANS DE MEDICAMENTOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

> TRATAMENTO APONTADO. Autora foi diagnosticada com "carcinoma de mama ductal infiltrante ", tendo realizado diversos tratamentos que não foram capazes de impedir o progresso da doença. Relata que sua condição se agravou, razão pela qual o médico que a acompanha prescreveu a medicação " IBRANCE" associado a "FULVESTRANT". Contudo, a ré não autorizou a cobertura da medicação. Cabe ao médico do paciente, diante do caso concreto, analisar qual o medicamento ou insumo que se adequa melhor ao caso, e não ao Plano de Saúde. Entendimento pacificado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de fornecer o tratamento, ainda que não haja indicação na bula, mas tenha sido indicado pelo médico. Conduta do plano que se mostra abusiva, ao impedir o paciente de receber o tratamento com método recomendado pelo médico que acompanha a parte. Dano moral. Existência. A injusta recusa do plano de saúde, no caso o fornecimento do medicamento descrito na inicial, colocou em risco a vida da consumidora, o que, com certeza, ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento. Valor de R$ 10.000,00 que foi fixado de forma razoável e proporcional. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
> (0134643-23.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR - Julgamento: 06/04/2022 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Forte nessas razões, impõe-se a procedência dos pedidos, a fim de condenar a requerida a custear o medicamento indicado na inicial, na quantidade indicada pelo médico que acompanha a autora (fls. 47/50), por prazo indeterminado, até que cesse o tratamento.

Dos danos morais

A doutrina ensina que o dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, é possível afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (GAGLIANO, Pablo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de direito civil. Vol. III. 4ª ed. 2006, p. 55).

Os danos psicológicos, na espécie, são in re ipsa, não reclamam prova robusta e são perfeitamente perceptíveis das circunstâncias do caso concreto, em razão da angústia, dor, sofrimento, tristeza, intranquilidade a que se submeteu a parte autora ante a negativa da requerida em custear o tratamento de urgência.

O dano moral é sensível e perceptível dos fatos narrados, que extrapolam o mero dissabor cotidiano, a medida que violaram direitos da personalidade como direito a dignidade, a vida e a integridade psicológica.

Nesse sentido existem precedentes jurisprudenciais:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. EFETIVA OPORTUNIDADE DE ADEQUAÇÃO PELO CONTRATANTE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. ENFERMIDADE DE CÂNCER DE MAMA. FÁRMACOS IBRANCE E SELETIV. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE APROVADOS PELA ANVISA. BULA QUE INDICA A PRESCRIÇÃO PARA A DOENÇA DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE ATENDIMENTO À DOENÇA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova que repute desnecessária, em especial se os demais elementos probatórios carreados aos autos já são suficientes para a resolução da demanda. 2. Não sendo efetivamente concedida pelo plano de saúde oportunidade ao consumidor de migração para plano mais abrangente e benéfico, tem-se por cabível a adequação dos dispositivos da Lei n.º 9.656/98 ao contrato firmado antes de sua vigência, sendo inaplicáveis aqueles de cláusulas restritivas do contrato inicial. 3. Não é experimental o medicamento quando devidamente registrado na ANVISA e cuja bula indica, expressamente, a prescrição para uso em doença que acomete o autor. 4. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer quais são as doenças às quais serão oferecidas coberturas, mas não podem escolher o tipo de tratamento a ser utilizado. 5. O transtorno sofrido pelo apelado diante da recusa da operadora do plano de saúde em fornecer a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

> medicação prescrita não pode ser visto como mero dissabor do cotidiano, eis que, em verdade, revela a existência de dano moral a ser indenizado. 6. Recurso não provido.
>
> (**TJMS**. Apelação Cível n. 0815261-92.2019.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 24/03/2022, p: 29/03/2022)

Uma vez configurado o dano, resta fixar a indenização garantida constitucionalmente à autora, *ex vi* do **art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal**.

A reparação do dano moral, sabe-se, constitui-se de um binômio compensação e punição, pois busca compensar o que experimentou o dano e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, inclusive para desestimulá-lo a prática semelhante.

Portanto, indenizar, nas palavras de **Rui Stoco**, *"significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível, restaurando o statu que ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do dano"*.

Tratando de ação de indenização por danos morais em hipótese que inexistem critérios objetivos para a fixação de valores, deve o juiz arbitrá-lo de acordo com as peculiaridades da espécie, considerando-se as condições pessoais do ofendido, o grau da culpa, sua potencialidade e a extensão do dano causado e a situação econômica do agente ofensor.

É importante lembrar da situação econômica da requerente, que aparentemente se releva normal e, da requerida é, seguramente, confortável. A parte autora não contribuiu para que o evento ocorresse e, deve-se lembrar que a indenização não pode se constituir em fonte de enriquecimento ilícito, vez que se trata de modalidade de compensação pelo dano moral experimentado.

Diante dessas circunstâncias, revela-se razoável que a indenização pelo dano moral seja fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois valor menor não se prestaria a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

cumprir com os fins da indenização, que, repita-se, são a ***compensação*** do sofrimento da vítima e a ***penalização*** do ofensor.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do **art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil**, solvendo o mérito da controvérsia e pondo fim à fase cognitiva, **ACOLHO O PEDIDO DO AUTOR**, para:

I – **CONDENAR** o REQUERIDO ao custeio do tratamento com o medicamento indicado na inicial (PALBOCICLIBE - IBRANCE), na quantidade indicada pelo médico que acompanha a autora (fls. 47/50), por prazo indeterminado, até que cesse o tratamento por indicação médica;

II – **CONDENAR** o REQUERIDO ao pagamento de indenização por **danos morais** em favor do AUTOR no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(a) – Os juros simples (1% ao mês) serão contados a partir da citação (CC 405 – responsabilidade contratual) e a correção monetária (IGPM-FGV) a partir da data do arbitramento (STJ – Súmula 362).

III – Com fundamento no **art. 85, e §§, e seguintes, todos do Código de Processo Civil**, e tendo em vista o julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça** do **Tema Repetitivo nº 1.076** [*i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo], **CONDENO** o REQUERIDO ao pagamento das **custas processuais** e **honorários**, sendo que estes últimos – atendido o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, a complexidade do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – fixo em **10%** do valor do proveito econômico obtido.

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS:

(i) nos casos de rejeição integral dos pedidos, se concedida **tutela de urgência** [*in limine* ou *incidenter*], esta automaticamente terá seus efeitos revogados nesta data, exceto se expressamente deliberado de outra forma na decisão.

(ii) se for o caso, nos casos de condenação de pagar (principal ou honorários), havendo o depósito nos autos, e concordando a parte contrária (ou silente), **desde já fica autorizado o levantamento dos valores**, independente de despacho.

(iii) se concedida a assistência judiciária gratuita, a exigibilidade dos honorários e consectários legais em face da parte beneficiada fica suspensa.

(iv) cumpram-se as demais disposições pertinentes e aplicáveis à espécie previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Campo Grande, *data da assinatura digital*.

ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO – *ASSINATURA DIGITAL*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2022 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830510-52.2020.8.12.0001 e código ib6ygeES.